

1500961-12.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO.

QUALIFICADORAS MANTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, inciso I e II, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

Foro de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, Centro, Cachoeira Paulista - SP - cep 12630-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500961-12.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2301977/2021 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 21230335 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 943/21/210 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 2301977 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DJALMA DE OLIVEIRA

Vítima:

GIOVANA CÉLIA GARCIA DOS SANTOS e outro

Data da Audiência:

23/11/2022

Aos 23 de novembro de 2022, nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, às 16h00min, na Sala Virtual de Audiências no aplicativo Teams, onde presente se encontrava o(a)MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª Vara desta Comarca, Exmo. Srº Drº. Gabriel Araújo Gonzalez, comigo, Escrevente Técnico Judiciário, a seu cargo, abaixo nomeado, foi aberta, com as formalidades legais, a audiência designada nos autos sob nº 1500961-12.2021.8.26.0621, do Processo Crime que a Justiça Pública move contra DJALMA DE OLIVEIRA, para audiência de instrução, debates interrogatório e julgamento. Aberta a audiência por videoconferência, verificou-se a presença do(a) Dr(a). Marcela Agostinho Gomes Ilha, DD. 2ª Promotor(a) de Justiça desta Comarca, a vítima, testemunha e o Advogado Dativo do réu, Drº Leandro Danze Guimarães Leonor- Oab/Sp 248.198. Ausente a testemunha Paulo Antonio Sodero Martins Júnior e o réu, pois ambos não localizados no endereço fornecido. Iniciados os trabalhos, às 16h00min, foi

ouvida a vítima Giovana Célia Garcia dos Santos e a testemunha Maurício da Conceição Silva, cujos depoimentos foram gravados em mídia audiovisual. Pelo Ministério Público foi dito que: Desistia da oitiva da testemunha Paulo Antonio Soderro Martins Júnior, ausente neste ato. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que : Decreto a revelia do réu e homologa a desistência da testemunha requerida pelo Ministério Público, e, não havendo mais provas a serem produzidas, nem requerimentos formulados pelas partes de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal), declaro encerrada a instrução e determino que se passem aos debates orais, o que foi apresentado pelo Ministério Público e Defesa técnica e gravados em mídia audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida contra DJALMA DE OLIVEIRA pela suposta prática do crime do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II (escalada) c.c artigo 14, inciso II, e no artigo 307, caput, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Na denúncia, narra-se que:

[...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo Promotor de Justiça infra-assinado, no uso e gozo de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com base no incluso inquérito policial, oferecer DENÚNCIA em face de DJALMA DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 08, pelo fato punível que passa a relatar.

Consta do inquérito policial que, no dia 05 de novembro de 2021, às 13h14, na Rua Sete de Setembro, nº 538, Centro, nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, DJALMA DE OLIVEIRA tentou subtrair, mediante escalada, uma bicicleta roxa, sem marca aparente, aro 26, quadro nº 19A10142, avaliada em R\$800,00 (oitocentos reais), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e auto de avaliação de fl. 11, pertencente a Giovana Celia Garcia dos Santos, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço supramencionadas, DJALMA DE OLIVEIRA atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Apurou-se que, na data sobredita, DJALMA transitava pela via pública, oportunidade em que divisou a bicicleta de propriedade da vítima no interior da residência situada no local dos fatos e deliberou por subtraí-la.

Então, o denunciado escalou a grade da residência, apoderou-se da bicicleta e, quando ia lançá-la para fora das cercanias do imóvel, foi surpreendido por terceiro, que o deteve até a chegada dos policiais.

Com a chegada dos policiais, DJALMA apresentou-se aos policiais como sendo EDGAR DA SILVA, atribuindo a si falsa identidade para que a ocorrência não viesse a constar em seus registros policiais. [...]

À fl.76, houve o recebimento da denúncia.

Às fls.86/90 foi acostado laudo pericial.

À fl.125, o réu ofereceu resposta à acusação.

Às fls. 126/128, negou-se a absolvição sumária do Réu e foi designada audiência de instrução e julgamento.

Em 23/11/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Em alegações finais, o MP defendeu que: a ação deve ser julgada procedente, pois há prova de autoria e materialidade; há comprovação da qualificadora; há prova da falsa identidade; o Réu é primário; deve ser considerada a qualificadora.

Em alegações finais, a defesa afirmou que: o Réu deve ser absolvido; não teve contato com o Réu.

É o relatório. Passo a decidir.

II- FUNDAMENTAÇÃO

II.1 Do crime do art. 307, caput

No caso concreto, não há prova suficiente para a condenação.

Em sua oitiva em juízo, a vítima GIOVANA CÉLIA GARCIA DOS SANTOS afirmou que: trabalhava no endereço dos fatos; havia uma grade baixa no local; não viu nada; quando o patrão chegou em casa, viu um rapaz com uma bicicleta pendurada e pulando a grade, para furtar; o padrão gritou e não deixou ele levar bicicleta; era uma bicicleta roxa; recuperou a bicicleta; viu o rosto do Réu, mas não consegue lembrar.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha MAURÍCIO DA CONCEIÇÃO SILVA afirmou que: na data dos fatos, foram acionados pelo 190 para atender uma ocorrência de furto; no local, encontraram o Réu detido pelo dono da residência (Paulo); Paulo informou que, chegando na residência, viu o Réu atravessando a bicicleta pela grade da frente da residência e deteve o Réu; o Réu confessou que pulou a grade para pegar a bicicleta; não encontraram nada de ilícito com o Réu; o Réu encaminhado à delegacia.

Como se sabe, a condenação criminal exige um grau muito elevado de probabilidade quanto às alegações de fato, a ponto de haver o dever de absolver quando não há provas ou quando existe uma dúvida razoável em favor do acusado:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VI - existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VII - não existir prova suficiente para a condenação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz:

I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade;

II - ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas;

(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

III - aplicará medida de segurança, se cabível. (grifos acrescentados)

No caso concreto, as provas não sustentam a acusação suficientemente, já que nada sobre isso foi perguntado ao policial ouvido em juízo.

Desta forma, o Réu deve ser absolvido com base no art. 386, VII, do CP, quanto ao crime do art. 307, caput, do CP.

II.2 Do furto qualificado

Da autoria e da materialidade

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

Em sua oitiva em juízo, a vítima GIOVANA CÉLIA GARCIA DOS SANTOS afirmou que: trabalhava no endereço dos fatos; havia uma grade baixa no local; não viu nada; quando o patrão chegou em casa, viu um rapaz com uma bicicleta pendurada e pulando a grade, para furtar; o padrão gritou e não deixou ele levar bicicleta; era uma bicicleta roxa; recuperou a bicicleta; viu o rosto do Réu, mas não consegue lembrar.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha MAURÍCIO DA CONCEIÇÃO SILVA afirmou que: na data dos fatos, foram acionados pelo 190 para atender uma ocorrência de furto; no local, encontraram o Réu detido pelo dono da residência (Paulo); Paulo informou que, chegando na residência, viu o Réu atravessando a bicicleta pela grade da frente da residência e deteve o Réu; o Réu confessou que pulou a grade para pegar a

bicicleta; não encontraram nada de ilícito com o Réu; o Réu encaminhado à delegacia.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito.

Na situação sob julgamento, a materialidade delitiva do furto restou devidamente comprovada através dos seguintes elementos: boletim de ocorrência (fls. 5/7), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 12/13), pelo auto de avaliação (fl. 14), pelo laudo pericial (fls. 86/90), bem como nos demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Em audiência de instrução e julgamento, houve a comprovação de que: o Réu pulou o muro da residência para furtar a bicicleta da vítima, não conseguindo êxito por ter sido surpreendido pelo proprietário da casa.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado DJALMA DE OLIVEIRA foi o autor do crime do furto.

A qualificadora da "escalada" é aplicável àqueles casos nos quais o agente, para realizar a subtração, tem que subir em algum ponto mais elevado do que o caminho natural para o acesso à coisa:

"31. Escalada: é a subida de alguém a algum lugar, valendo-se de escada. Escalar implica subir ou galgar. Portanto, torna-se fundamental que o sujeito suba a algum ponto mais alto do que o seu caminho natural, ou seja, é o ingresso anormal de alguém em algum lugar, implicando acesso por aclave. Ex.: subir no telhado para, removendo telhas, invadir uma casa (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 960) (grifos acrescidos)

Segundo o STJ, a comprovação da escalada exige exame pericial, somente se admitindo a comprovação por via indireta quando não for possível a realização do estudo técnico:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO.

QUALIFICADORAS MANTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, inciso I e II, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.513.004/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/10/2015, DJe 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 26/3/2015.

(...)

(AgRg no HC 573.801/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

No caso concreto, o laudo de fls. 86/90 comprova a altura do muro (1,75m) e as provas produzidas em audiência, indicam que o Réu escalou o portão para entrar no imóvel e promover a subtração.

Nesse cenário, das provas constantes dos autos, se extrai que o réu DJALMA DE OLIVEIRA, de fato, na data de 05/11/2021 mediante escalada, tentou subtrair para si, coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta, avaliado em R\$800,00 de propriedade de GIOVANA CÉLIA GARCIA DOS SANTOS.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo art. 155, §4º, II, do Código Penal. Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que o réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu DJALMA DE OLIVEIRA pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, II, do CP, na forma tentada.

Da dosimetria da pena

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, a culpabilidade é natural à espécie. Posto isso, deixo de valorar negativamente esta circunstância judicial; b) Antecedentes: trata-se de acusado sem antecedentes criminais (conforme entendimento da súmula 444 do STJ), motivo pelo qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: tal circunstância também deverá ser valorada como neutra.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a reconhecer. Desta forma, fixo a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Não há causa de aumento a reconhecer.

Na terceira fase, não há causa de aumento a aplicar.

Por outro lado, é possível reconhecer a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, cuja redução se dá entre 1/3 e 2/3 (art. 14, parágrafo único, do CP).

Quanto à fração a ser aplicada, é entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência de que o critério deve ser o iter criminis percorrido pelo agente. No caso concreto, nota-se que o agente chegou a passar a bicicleta para o outro lado, mas ainda estava dentro da residência, razão pela qual aplico a causa de diminuição no patamar de 1/2.

Desta forma, a pena definitiva fica em 1 ano de reclusão e 5 dias multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena.

Considerando, entretanto, que o Réu preenche os requisitos do art. 44, I a III, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art.

44, § 2º, do CP), aplicando a prestação de serviços à comunidade, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP).
Incabível a sua suspensão condicional, diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 77, III).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva veiculada na denúncia para:

- a) ABSOLVER R o Réu DJALMA DE OLIVEIRA da imputação da prática do crime do art. 307, caput, do CP, com base no art. 386, VII, do CPP;
- b) CONDENAR o réu . DJALMA DE OLIVEIRA pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal, na forma tentada (art. 14, II, do CP) às penas de 1 ano de reclusão, ser cumprida em regime inicial ABERTO e ao pagamento de 5 dias-multa, no valor individual de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos. Considerando, entretanto, que o réu preenche os requisitos do art. 44, I a III, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do CP), aplicando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do CP.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO os sentenciados ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).
Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a prisão preventiva dos réus por entender ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante do regime inicial de cumprimento e da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva.

Após o trânsito em julgado, nos termos dos artigos 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, os objetos apreendidos ficarão disponíveis para os interessados, desde que comprovada a propriedade, pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, fica determinado seu perdimento, para posterior alienação em leilão ou destruição, se o caso.

COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Pelo Ministério Público foi dito que não irá recorrer da sentença
Providencie a z. serventia a juntada aos autos do link da audiência realizada nestes autos, para posterior acesso pelas partes. Nada mais havendo, às 16h33min foi encerrada a presente audiência com as formalidades legais. Do que, para

constar, lavrei este termo, o qual vai assinado digitalmente apenas pelo(a) MM(a). Juiz(a), nos termos dos arts. 1269 e 1270 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, Tomo I. Eu, Rosangela da Silva Fortunato Teixeira, Escrevente Técnico Judiciário, o digitei.

MM(a). Juiz(a): (assinado digitalmente)